

1500167-88.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-88.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039457/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 22952623 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2039457 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HUMBERTO FERREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

PAULO HUMBERTO FERREIRA DA SILVA e VICTOR GUIMARÃES MUNIZ OLIVEIRA foram

denunciados como incursos nas sanções do artigo 33, "caput", e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 10 de fevereiro de 2022, na rua São Marcos, nº 108, Cruzeiro, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e transportavam, para consumo de terceiros, 23 papелotes de cocaína, 14 porções de maconha e 92 pedras de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar a fls. 164/165 e 174/175. Recebida a denúncia aos 25 de abril de 2022 (fl. 179), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e duas da defesa. Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado Victor e decretou-se a revelia de Paulo, face sua mudança de endereço sem comunicação ao Juízo (fl. 242).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 246/254).

A defesa pugnou pelas absolvições embasadas na ausência de provas das autorias e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fls. 274/310 e 314/334).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está plenamente comprovada. Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 137/145) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são cocaína e maconha, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos as autorias também se evidenciaram.

Paulo não compareceu em Juízo para apresentar sua versão, demonstrando descaso com a Justiça e desinteresse em se defender.

Durante a etapa policial, ele negou a prática da infração, argumentando que não haveria drogas em sua casa naquele dia quando a polícia o encontrou em sua residência

Eis suas palavras naquela oportunidade:

"Hoje eu estava dentro da minha casa, deitado, os policiais entraram lá e perguntaram se tinha droga e se as drogas dentro das sacolas eram minhas. Falei que não. A sacola foi encontrada no meu quarto, mas eu estava na minha sala. Depois me levaram para a viatura e me trouxeram para a delegacia, mas nem sei o que foi encontrado. Em relação ao Vitor, conheço o Vitor de obra, trabalhamos juntos e conversamos algumas vezes, mas não somos próximos. Eu o vejo de vez em quando. Os dois celulares são meus." - fl. 11

Por sua vez, Victor negou que estivesse na posse de drogas no momento da abordagem policial.

Ora, sequer ele justificou a existência da droga apreendida durante a diligência, em que pese não haver dúvidas sobre a apreensão do entorpecente pelos policiais.

Não é crível que policiais inventem fatos ou "enxertem" a droga em desfavor de acusados, em especial quando sequer vestígio a respeito existe nos autos.

No mais, ele se escusou da imputação por meio de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais querer lhe imputar injustificadamente crime de tamanha gravidade.

Se não bastasse a força de convencimento nesses elementos, corroboram a certeza das autorias os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O PM Júnior narrou que naquela ocasião durante patrulhamento de rotina pela rua São Marcos avistou dois indivíduos conversando em frente a uma residência. Contou que quando Paulo notou a presença da viatura policial, tentou empreender fuga, correndo para o interior de um imóvel. No entanto, neste momento observou com segurança o

instante em que ele arremessou um embrulho ao solo.

Mencionou que o outro indivíduo que ali estava, coacusado Victor, imediatamente foi detido e abordado. Realizada revista pessoal, localizou em seu poder algumas porções de cocaína e pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro.

Continuando a diligência, seguiu até o lugar onde havia visualizado Paulo dispensando uma sacola e a recolheu, constatando que havia em seu interior 12 porções de cocaína, 14 porções de maconha e 79 pedras de crack, bem como o valor de R\$ 500,00, em dinheiro. Na sequência, Paulo saiu da residência em que estava, razão pela qual também foi detido.

Por sua vez, o PM Erick ratificou a versão apresentada por seu colega. Ele contou que naquela oportunidade, depois de terem capturado Victor, com quem tinham apreendido diversas porções de droga, seguiu até o local em que Paulo havia se desfeito de uma sacola, verificando que havia diversas porções de cocaína, maconha e pedras de crack em seu interior.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão dos acusados tivessem qualquer motivo para imputar a eles, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade dos agentes. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frise-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local e a abordagem dos agentes, assim como a apreensão das drogas, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara

de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escoreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) As testemunhas de defesa ouvidas não foram capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

Claudislaine contou que, quando chegou ao local, Victor já estava detido no interior da viatura policial. Salientou que logo em seguida, viu quando os policiais trouxeram o coacusado Paulo e também o colocaram na viatura. Declarou, também, que no momento em que os policiais levavam Paulo até a viatura, notou que

um deles carregava uma sacola na mão.

Por sua vez, a testemunha Ana Cristina não presenciou os fatos, somente trazendo relatos sobre a conduta social do coacusado Victor.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, a variedade de espécies, o local e as circunstâncias como foram encontrados os agentes, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenham os agentes efetuado a venda. Basta que a possuam ou tenham em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afinal, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, as condutas praticadas pelos acusados amoldam-se perfeitamente às figuras "trazer consigo e guardar", previstas no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma nos autos.

Não obstante os argumentos já expendidos em relação ao crime de tráfico, não deve prosperar a imputação de associação para tal finalidade.

Isto porque os acusados nada admitiram neste particular. Nenhum vestígio existe a respeito de uma eventual associação duradoura e estável entre eles. Os policiais nada relataram sobre a associação imputada.

O crime de associação se distingue do concurso eventual de pessoas que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinado crime; a associação pressupõe ajuste permanente ou estável para a perpetração de vários crimes de tráfico de entorpecentes (mínimo dois).

A propósito, dispõe o artigo 35: Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a reiteração ou não "jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da lei nº 11.343/2006, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer. O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição.

Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."(GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei n.º 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei 6368/76 - 12.ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, repise-se, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, in casu, o delito de associação.

Restando, pois, incomprovado o animus associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfico, pois, para a sua caracterização é indispensável à associação de duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; e a finalidade de traficar tóxicos, formando uma verdadeira *societas sceleris* para essa finalidade.

Não se vislumbrou a ocorrência de outros crimes de tráfico, como ainda, uma estabilidade na relação entre os acusados, razão pela qual suas absolvições se impõem.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos condenados não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade dos agentes.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

Ausentes as circunstâncias judiciais acima expostas, que deveriam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Na etapa derradeira, não foram observadas causas de aumento de pena.

Anote-se que, embora o coacusado Victor seja primário, constata-se que enquanto adolescente ele respondeu a diversos procedimentos por ato infracional, inclusive por ato análogo a tráfico de drogas, conforme ele mesmo declarou em seu interrogatório (fls.49/50).

Destarte, ainda que não seja possível sopesar os atos infracionais para considerá-lo reincidente ou portador de maus antecedentes, conforme entendimento reiterado do STJ, eles podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos previstos no § 4º, qual seja, não se dedicar às atividades criminosas.

Eis a Jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.022 - MG (2017/0284174-3) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR RECORRENTE : IGOR WASHINGTON SOUZA DA SILVA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUESTÕES PREJUDICADAS. Recurso especial desprovido. DECISÃO: Trata-se de recurso especial interposto por Igor Washington Souza da Silva, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0024.15.093125-1/001 (fls. 287/297): APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 INVIABILIDADE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA BENEFÍCIOS NÃO RECOMENDÁVEIS ISENÇÃO DAS CUSTAS IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, é impossível a absolvição. Não é possível aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 se o acusado não preencher todos os requisitos, que são: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa. A quantidade do entorpecente apreendido e a dedicação do acusado a atividades criminosas relacionadas ao tráfico revelam a maior reprovabilidade da conduta do condenado e demonstra não ser suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime em questão a fixação de regime prisional diverso do fechado. Não é possível substituir a pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 04 anos (art. 44 do CP). O recurso especial aponta a violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; porque negada a aplicação da causa de diminuição de pena com suporte na prática de atos infracionais. Pede o conhecimento e provimento do Recurso Especial para que seja aplicada a referida minorante; de forma subsidiária, pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Oferecidas contrarrazões (fls. 316/318), foi admitido o recurso na origem (fls. 320/321). O Ministério Público Federal opina pelo não provimento da insurgência (fls. 332/334). RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA, PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, NEGADA, POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. É o relatório Quanto ao pedido de aplicação da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, extrai-se os seguintes fundamentos do combatido aresto (fls. 294/295 grifo nosso): [...] Razão também não assiste à defesa em requerer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Segundo determina o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para que o condenado faça jus à redução da pena de um sexto a dois terços, deve preencher quatro requisitos: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) não integrar organização criminosa. No presente caso, a despeito de o apelante ser primário e possuir bons antecedentes, entendo que há elementos para afirmar que ele se dedica a atividades criminosas. Isso porque os vários registros da prática de atos infracionais pelo acusado, embora não possam ser aferidos como maus antecedentes para elevar a pena - base ou para caracterizar a reincidência, evidenciam a sua inclinação a práticas delitivas. Destaco que o acusado confessou o seu envolvimento com o tráfico ao afirmar que "fica na boca de fumo de 10:00hs às 18:00hs como atividade" e que "foi apreendido por ato análogo ao art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal; que nessa ocasião o interrogando tentou contra a vida de outra pessoa pois estava cobrando dívida de tráfico de drogas" (sic, fl. 120). Convém destacar que o STJ vem decidindo que o envolvimento do agente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando estiverem relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, pode justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente

a práticas criminosas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: O envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas, é elemento capaz de afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na medida em que revela a sua dedicação em atividades criminosas. Precedente: HC 299.673/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/812016. (HC 333.749/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017). O registro de atos infracionais é elemento idóneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma. (HC 364.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). Portanto, ante o não preenchimento dos requisitos necessários, não é possível aplicar ao apelante a benesse em questão. [...] Com efeito, a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A propósito, precedentes de ambas as Turmas: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro na quantidade, na natureza e na diversidade das drogas apreendidas, no registro de ato infracional análogo tráfico de entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas e integra facção criminosa, a alteração desse entendimento para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idóneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar as regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também o art. 42 da Lei de Drogas. 6. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do CP. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para fixar regime inicial semiaberto. (HC n. 423.378/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2017 grifo nosso).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é

necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.560.667/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2017 grifo nosso).

Por sua vez, Paulo é primário, portador de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou integre organização criminosa. Logo, amolda-se na hipótese de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, suas penas serão diminuídas em 2/3 (5 anos - $2/3 = 1$ ano e 08 meses/500 dias - $2/3 = 166$ dias).

Para início do cumprimento da pena fixo o regime aberto para Paulo, levando em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, a sua primariedade, o reconhecimento do tráfico privilegiado e do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 596.603:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. Ante a necessidade de salvaguardar um dos direitos fundamentais mais preciosos do ser humano, a liberdade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 143.641/SP, rompeu com a resistência registrada nos seus precedentes, quanto à inadmissibilidade do uso do writ constitucional de maneira coletiva. Na oportunidade, assentaram-se diretrizes a respaldar o maior espectro do remédio heroico, entre elas: a existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis; o fortalecimento da abordagem coletiva, em atendimento a maior isonomia às partes em litígio e em prestígio à celeridade processual, mitiga as dificuldades estruturais do acesso das coletividades ao Poder Judiciário. 2. A moldura fática trazida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo - mais de mil presos, que, a despeito da reconhecida prática de crime de tráfico privilegiado, cumprem pena de um ano e oito meses, em regime fechado, com respaldo exclusivo no ultrapassado entendimento de que a conduta caracteriza crime assemelhado a hediondo - permite solução coletiva, por reproduzirem a mesma situação fático-jurídica. Precedente (HC n. 575.495/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020). 3. Há anos são perceptíveis, em um segmento da jurisdição criminal, os reflexos de uma postura judicial que, sob o afirmado escudo da garantia da independência e da liberdade de julgar, reproduz política estatal que se poderia, não sem exagero, qualificar como desumana, desigual, seletiva e preconceituosa. Tal orientação, que se forjou ao longo das últimas décadas, parte da premissa equivocada de que não há outro caminho, para o autor de qualquer das modalidades do crime de tráfico - nomeadamente daquele considerado pelo legislador como de menor gravidade -, que não o seu encarceramento. 4. Segundo a interpretação, consolidada e antiga do Supremo Tribunal Federal (HC n. 111.840, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/12/2013), conforme à Constituição da República, não é considerado hediondo o delito de tráfico de

drogas, na modalidade prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 (caracterizada pela quantidade de drogas apreendida não elevada e por ser o agente primário, sem antecedentes penais e sem envolvimento com atividade ou organização criminosa). 5. Em decorrência dessa interpretação, que sobreleva os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, a natureza não hedionda do crime em exame desautoriza prisão preventiva sem a análise concreta dos requisitos do art. 312 do CPP (HC n. 104.339, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 06/12/2012), afasta a proibição, prevista art. 44 da Lei 11.343/2006, de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (HC n. 97.256, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 15/12/2010), e impõe, portanto, tratamento penal com "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (HC n. 118.533, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/9/2016). 6. Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, é clara e reiterada a dicção de enunciados sumulares dos Tribunais Superiores, segundo os quais "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Sum. 718 do STF), "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Sum. 719 do STF) e "É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito" (Sum. 440 do STJ). 7. Esses julgados, por força do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão da norma de abertura positivada no art. 3º do CPP, devem ser observados por juízes e tribunais do país, em nome da segurança jurídica, da estabilidade das decisões do Poder Judiciário, da coerência sistêmica e da igualdade de tratamento dos jurisdicionados, que não podem ficar à mercê de interpretações divergentes, sobre questões de cunho eminentemente jurídico, das que lhes conferiram os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, incumbidos, por comando constitucional, da função de uniformizar a interpretação e a aplicação da Constituição da República e das leis federais (arts. 102, III e 105, III). 8. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 9. Deveras, não condiz com a racionalidade punitiva, insita a um Estado Democrático de Direito, que a todo e qualquer autor de tráfico de drogas se imponha o cumprimento de sua pena em estabelecimento penal, em regime fechado, e sem direito a qualquer alternativa punitiva, mesmo se todas as circunstâncias judiciais e legais sejam reconhecidas a seu favor (quantidade pequena de droga, primariedade e bons antecedentes do agente, além de não demonstração de seu envolvimento em atividade ou organização criminosa). 10. E não há de ser esse o proceder de agentes do Estado a quem se confia o exercício da nobre função de dizer o Direito, algo que, no âmbito da jurisdição criminal – que expressa o poder punitivo estatal – reclama dose ainda maior de serenidade e ausência de preconceitos. 11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis. 12. A documentação, trazida em aditamento à impetração, alude a 1100 homens e mulheres que cumprem pena em regime fechado no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, e sem lhes haver sido

autorizada a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos, a despeito de terem sido condenados à sanção mínima do tráfico privilegiado (1 ano e 8 meses de reclusão), ou, quando muito, a uma pena menor que 4 anos de reclusão. A menos que cumpram pena por outro motivo, são pessoas que se encontram indevidamente recolhidas ao precário sistema penitenciário, onerando ainda mais a sociedade, que poderia se beneficiar com serviços comunitários, houvessem as respectivas sanções reclusivas sido convalidadas em restritivas de direito. 13. Se a lei é, na visão de julgadores, benevolente com algum tipo de crime, compete ao Congresso Nacional, legitimado pelo voto popular, modificá-la (sempre sujeito, evidentemente, ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal). Não cabe ao Poder Judiciário, o uso de discursos metajurídicos de matiz ideológico ou moral, para incrementar o rigor do sistema punitivo e para contornar, com argumentos aparentemente jurídicos, os limites impostos pela lei penal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os quais, como visto, pela Constituição da República têm a especial competência para interpretar e uniformizar a lei federal e a Constituição em última instância, ante idênticas situações fáticas. 14. Estudo feito pelo Instituto Conectas (relatório disponível no sítio do instituto na web) conclui que “ainda que a decisão do STF no HC 118.533 tenha sido o reconhecimento do tráfico privilegiado como um crime comum, afastando-se a hediondez dos casos em que há aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, com a presente pesquisa verifica-se que juízes de primeira instância, em São Paulo, continuam aplicando tratamento desproporcional ao delito, em comparação com outros delitos sem violência de igual pena.” Alguns julgados – prossegue o relatório – “são expressos em sua afronta à jurisprudência dominante das cortes superiores, tecendo palavras fortes contra a

evolução interpretativa e constituindo, dentro da sua esfera de poder, um espaço blindado contra o tratamento proporcional aos condenados por tráfico de drogas, em qualquer grau.” 15. Pelos dados do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores - Brasília/DF, a Defensoria Pública de São Paulo em 2019, dos 11.181 habeas corpus impetrados no STJ, a ordem foi concedida em 6.869 feitos, 61,43% das impetrações. Mais ainda, aquela Defensoria evidenciou que, no período da pandemia, conforme Levantamento do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, em casos de reconhecido tráfico de menor monta (pouca quantidade de drogas, réus com bons antecedentes e sem provas de anterior atividade ilícita e de integração a organização criminosa), de 64 casos em que Câmaras Criminais do TJSP mantiveram a condenação de acusados por tráfico privilegiado, 53 foram reformadas pelo STJ, ou seja, cerca de 82,80% dos pacientes obtiveram decisão concessiva. 16. Esses dados são a tradução, inequívoca e indelével de que o volume de trabalho das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, ocupadas em mais de 50% por habeas corpus oriundos do Tribunal de Justiça de São Paulo (dos 68.778 habeas Corpus distribuídos no STJ em 2019, 35.534 vieram daquele Tribunal), em boa parte se resume a simplesmente reverter decisões que, contrárias às súmulas e à jurisprudência das Cortes Superiores, continuam a grassar, crescentemente, em algumas das 16 Câmaras Criminas daquele Tribunal. 17. Essa insistente desconsideração de alguns órgãos judicantes às diretrizes normativas derivadas das Cortes de Vértice produz um desgaste permanente da função jurisdicional, com anulação e/ou repetição de atos, e implica inevitável lesão financeira ao erário, bem como gera insegurança jurídica e clara ausência de isonomia na aplicação da lei aos jurisdicionados. 18. Em suma, diante da mesma situação factual – tráfico de pequena monta, agente primário, sem antecedentes penais, sem prova de vínculo com organização criminosa e de exercício de atividade criminosa (que não seja, é claro, a específica mercancia ilícita eventual que lhe rendeu a condenação) –, há de reconhecer-se que: 18.1. A Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), em seu art. 112, § 5º (com a redação que lhe conferiu a Lei n. 13.964/2019) é expressa em dizer que “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”; 18.2. O Ministério Público, a par da função exclusiva de exercitar a ação penal pública, é também constitucionalmente incumbido da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis" (art. 127, caput, da C.R.), e deve agir de acordo com critérios de objetividade, compromissado, pois, com o direito (custos iuris) e com a verdade (obbligo di verità, na dicção de LUIGI P. COMOGLIO e VLADIMIRO ZAGREBELSKY, Modelo accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano: Giuffrè, ano 36, fasc. 2 – aprile-giugno/1993, p. 484). Logo, a acusação formulada pelo Ministério Público há de consubstanciar uma imputação responsavelmente derivada da realidade fático-jurídica evidenciada pelo simples exame do inquérito policial, muitas vezes já indicativa de que não se cuida de hipótese de subsunção da conduta do agente ao crime de tráfico de drogas positivado no caput do art. 33 da LAD.

18.3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores – quer por meio de súmulas (verbetes n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ), quer por meio de julgamentos proferidos pela composição Plena do Supremo Tribunal Federal, seguidos por inúmeros outros julgamentos da mesma Corte e do STJ – é uníssona e consolidada no sentido de que:

18.3.1. Não se pode impor regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito e sem a idônea motivação, que não pode decorrer da mera opinião do julgador; 18.3.2. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador; 18.3.3. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e nas ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 18.3.4. O autor do crime previsto no art. 33, § 4º da LAD não pode permanecer preso preventivamente, após a sentença (ou mesmo antes, se a segregação cautelar não estiver apoiada em quadro diverso), porque: a) O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal – e copiosa jurisprudência das Cortes Superiores – afastou a vedação à liberdade provisória referida no art. 44 da LAD; b) Não é cabível prisão preventiva por crime punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos (art. 313, I do Código de Processo Penal; c) O tempo que o condenado eventualmente tenha permanecido preso deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º do CPP), o que, a depender do tempo da custódia e do quantum da pena arbitrada, implicará imediata soltura do sentenciado, mesmo se fixado o regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto (dado que, como visto, não se mostra possível a inflição de regime fechado ao autor de tráfico privilegiado).

19. Essas são, portanto, as diretrizes que devem ser observadas – e normalmente o são, pela maioria de juízes e tribunais de todo o país –, por decorrerem de precedentes qualificados das Cortes Superiores (súmulas de jurisprudência, julgamentos pelo Tribunal Pleno do STF, recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos do STJ, e extraordinários em repercussão geral, pelo STF), sobre questões jurídicas assentadas a partir da mesma situação fática, sempre ressalvada, naturalmente, a eventual indicação de peculiaridades do caso examinado, a permitir, mediante idônea e responsável motivação, distinguir a hipótese em julgamento da que fora decidida nos referidos precedentes.

20. Na espécie, a gravidade excepcional do delito não se sustenta, visto que o crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço e, embora apreendidas cocaína e crack, a quantidade da droga, ao contrário do afirmado, não foi relevante (5,6 g no total).

21. Habeas Corpus concedido, para:

21.1. Em relação ao paciente individualizado na impetração, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.

21.2. Em relação aos presos que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto.

21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão – salvo os casos do item anterior – determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a